

1500862-74.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... em pontos da via pública onde realizam o tráfico, sem exercerem forte vigilância sobre eles.

Confirma a prática delitiva o fato de o réu estar parado em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas e ter agido de forma suspeita ao avistar a viatura policial, correndo em disparada para tentar evitar a abordagem.

E aqui, abre-se parênteses para se registrar que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500862-74.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500862-74.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161050/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25544206 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2161050/2022 -

DEL.POL.CHARQUEADA, 2161050 - DEL.POL.CHARQUEADA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY VINÍCIUS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

WESLEY VINICIUS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de junho de 2022, por volta das 18 horas e 30

minutos, na rua Silvio Sartori nº 153, bairro Jardim Alvorada II, na cidade de Charqueada, nesta comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 13 porções de maconha (vegetal contendo THC), com massa bruta aproximada de 26,6g; 72 eppendorfs contendo cocaína em pó, com massa bruta aproximada de 45,8g e 52 porções de cocaína na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 15,3g (cf. laudo do exame químico-toxicológico de fls. 88/89 e boletim de ocorrência de fls. 15/21), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais patrulhavam pelo lugar indicado, conhecido ponto de venda de drogas, quando notaram que Wesley, antes postado no local, colocou-se em fuga, correndo, quando percebeu a aproximação da viatura, sendo perseguido e alcançado.

O acusado foi abordado pelos servidores públicos e submetido à busca pessoal, constatando-se, assim, que ele trazia consigo, para fins de tráfico, 5 eppendorfs contendo cocaína, 2 celulares, várias chaves e R\$ 65,00 provenientes do comércio de drogas.

Narra, ainda, que os guardas retornaram ao local onde Wesley foi visto inicialmente e encontraram outros 46 eppendorfs contendo cocaína, idênticos àqueles que estavam em poder dele, bem como, à distância de aproximadamente 5m deste local, uma sacola plástica contendo 52 porções de cocaína em forma de "crack", 21 eppendorfs contendo cocaína e 13 porções de maconha, tudo pertencente ao ao acusado.

Conclui a denúncia que a quantidade, o fracionamento, a forma do acondicionamento e as circunstâncias do flagrante evidenciaram que as substâncias apreendidas se destinavam ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 109). Defesa preliminar apresentada às fls. 117/121. Após, a denúncia foi recebida (fls. 128/129) e o réu foi citado às fls. 171.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma arrolada pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito. Pede o afastamento do privilégio e a fixação das penas com maior rigor, alegando que o réu é multirreincidente e gozava de livramento condicional na data dos fatos.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/21; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e fotografia de fls. 46; pelo laudo de constatação provisória de fls. 26/28 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 87/89, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 10/12), o réu permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), disse que estava no local dos fatos, o qual é usado como ponto de tráfico e de uso de drogas. No dia, os guardas abordaram três pessoas na esquina, Igor, Reginaldo e Mainã, os quais estavam de 10 a 15 metros de onde estava. Depois da abordagem dos três, também foi abordado por eles. Estava com cinco pinos de cocaína, para seu uso, os quais comprou uns 20 a 30 minutos antes da abordagem. Negou relação com as drogas encontradas no mato. Disse que não tentou fugir quando viu a viatura. Não correu. Não tinha desavença com os guardas antes dos fatos. No dia dos fatos tinha usado drogas com Reginaldo na rua de cima, uma hora antes da abordagem. Estava com dois celulares, um (Samsung mais antigo) era seu e outro (Samsung mais novo) de Mainã.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 06/07) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda civil Vinicius Ramos de Oliveira declarou que, no dia da ocorrência, estavam em patrulhamento pelo bairro e, quando entraram na rua Silvio Sartori, em local onde ocorre intenso comércio de drogas (o ponto de tráfico mais movimentado da cidade), avistaram o acusado na via pública parado manuseando o celular e perceberam que, ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga, correndo a pé em direção oposta à que vinham. Diante da atitude suspeita, saíram atrás do réu e o abordaram. Na revista pessoal, encontraram no bolso de sua roupa 5 microtubos, de cor branca, contendo cocaína, dois celulares, várias chaves e R\$ 65,00 em notas diversas. Relatou que retornaram até o local em que o acusado estava parado antes da fuga e ali, debaixo de uma telha, localizaram um frasco contendo 46 microtubos de cocaína, semelhantes ao que estavam na posse dele. A cinco metros de distância desse local, encontraram mais uma sacola branca, contendo 52 porções de crack, 21 pinos, na cor rosa, contendo cocaína e 13 porções de maconha. Esclareceu que, ao ser questionado, o acusado negou a posse das drogas, alegando que não tinha mais nada para falar. Explicou que, no local onde estavam escondidas as drogas, não havia nenhuma outra pessoa suspeita. Havia apenas algumas pessoas na rua e numa lanchonete (num ponto comercial fixo e não "trailer") um pouco mais distante, de 50 a 100 metros dali. Nas proximidades há uma área verde fechada por um alambrado.

O guarda civil Gian Gouvea Genguini, embora quando ouvido em juízo (gravação), disse não se recordar mais dos fatos, esclarecendo que atualmente encontra-se preso e não atua mais como guarda municipal, quando ouvido na fase informativa no dia dos fatos (fls. 08/09), prestou idêntica versão à de seu parceiro de farda.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM

JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes públicos: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

O depoimento da testemunha arrolada pela defesa não tem o condão de afastar a força da palavra dos agentes do Estado, eis que foi contraditório com a versão dada pelo próprio acusado.

De fato, Reginaldo Rodrigues Meneguini, ouvido em audiência (gravação), declarou que, no dia dos fatos, estava descendo a rua e foi abordado pelos policiais na frente do "Kuka Lanches". Os policiais lhe perguntaram se estava com droga, mas não a tinha. O réu também foi abordado e, com ele, foram encontrados dois celulares (divergência: o réu admitiu que, além dos celulares, trazia cinco porções de cocaína). Uma moça cujo nome desconhece também foi abordada. Declarou que foi liberado, mas o réu não. Não soube dizer o horário dos fatos, afirmando apenas que foi no período da noite. Alegou que é usuário e estava na rua usando drogas. O réu também é usuário. Tinha ido comprar drogas com o réu, mas ele não adquiriu entorpecente porque estava sem dinheiro (divergência: o réu falou que pouco antes havia comprado as 5 porções de cocaína). Não sabe o motivo pelo qual o réu tinha dois celulares. Não o viu com chaves, dinheiro ou alguma outra coisa no dia dos fatos. Não presenciou os policiais encontrando alguma chave com o réu. O local onde comprou drogas ficava distante de 15 a 20 metros do local da abordagem. Quando os traficantes veem a viatura chegando, eles correm. A polícia acaba abordando os usuários. Uma hora e meia antes dos fatos havia usado drogas com o réu.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e mantinha em depósito os entorpecentes descritos na denúncia, os quais se destinavam ao comércio e consumo de terceiros.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos guardas civis no sentido de que as drogas estavam, parte na sua posse, outra parte no exato ponto onde o acusado estava antes de tentar se evadir, e o restante nas proximidades (5 metros desse local).

Não há dúvidas de que todas as drogas pertenciam ao acusado, pois os guardas esclareceram que não havia nenhum outro suspeito nas proximidades.

E os traficantes não deixam seus entorpecentes escondidos em pontos da via pública onde realizam o tráfico, sem exercerem forte vigilância sobre eles.

Confirma a prática delitiva o fato de o réu estar parado em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas e ter agido de forma suspeita ao avistar a viatura policial, correndo em disparada para tentar evitar a abordagem.

E aqui, abre-se parênteses para se registrar que inexistiu ilicitude na ação dos guardas civis.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado, como ocorreu no caso dos autos, em que o réu foi visto em situação de fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico de drogas, o que permitiu a ação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais.

Neste sentido, diversos precedentes:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas- Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO - j. 05/10/2020) - g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA.

RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 25/08/2020) - g.n.

Prosseguindo na análise do contexto fático, registre-se que, quanto ao destino mercantil dos entorpecentes apreendidos, ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade e variedade de drogas relacionadas ao réu, totalmente incompatíveis com a situação do mero usuário, e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografia de fls. 46)

Outrossim, com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 65,00, em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada (nenhum elemento dos autos indica que o réu trabalhava no "Muka Lanches", como sustenta a Defesa técnica), o que reforça a convicção de que era fruto do comércio ilícito que ele ali exercia.

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentarem o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas.

Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastados a tese defensiva de insuficiência probatória e o pedido subsidiário de desclassificação para o crime do artigo 28 da referida lei.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A diversidade de drogas e a quantidade, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não se faz presente nenhuma circunstância atenuante.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (trata-se de dupla

reincidência, sendo uma delas específica: fls. 102: condenado por tráfico no processo nº 0000514-72.2018.8.26.0599, da 2ª V.C. local, cujo trânsito em julgado se deu aos 14/10/2020, e outra por delito grave: fls. 102/103: condenado por roubo e corrupção de menor, no processo nº 0000514-72.2018.8.26.0599, da 3ª V.C. local, cujo trânsito em julgado se deu aos 05/02/2018).

Tratando-se de dupla reincidência, uma delas específica e outra pelo grave crime de roubo, as penas devem ser aumentadas na segunda fase para seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e, tratando-se de dupla reincidência e, inclusive, específica, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando na prática criminosa.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confirmam-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

"Apelação Criminal. Tráfico. Apreensão de 312 gramas de maconha, no interior de estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil, demonstradas pelo acervo coligido - Depoimentos de agentes de segurança penitenciária, seguros e sem contradições, cujo teor foi corroborado pela confissão judicial - Crime caracterizado que afasta a pretensão desclassificatória - Condição de usuária (sequer aventada pela ré) que não impede a prática do tráfico ilícito nem é suficiente para descaracterizá-lo - Majorante configurada (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional) - Dosimetria - Reincidência (específica) e gravidade concreta do delito que obstam a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime prisional fechado para o início da expiação - Condenação confirmada em 2º grau que exige a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação - Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - Apelo defensivo, não

provido, com determinação." (TJSP - Apelação 0016048-25.2016.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) -g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão cautelar do réu não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu WESLEY VINICIUS DA SILVA a cumprir seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado (R\$ 65,00) é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu é duplamente reincidente, inclusive específico, o que indica real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA